

1501516-24.2020.8.26.0537

Classe: Auto de Prisão em Flagrante

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Patrícia Helena Hehl Forjaz de Toledo

Comarca: Diadema

Foro: Foro de Diadema

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 18/05/2022

... que dependentes químicos utilizam o tráfico de entorpecentes como meio de perpetuar o vício, de modo que as condutas coexistem, não se excluem, donde afastado o pedido de desclassificação. A condição de usuário não elide a responsabilização do agente pelo tráfico de drogas, pois é comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, o qual vende entorpecente para ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Diadema

Foro de Diadema

2ª Vara Criminal

Avenida Sete de Setembro, 399, Diadema-SP - cep 09912-010

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501516-24.2020.8.26.0537 - Controle nº 2020/001253

Classe – Assunto:

Auto de Prisão em Flagrante - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2210950/2020 - SIG

DEL.SEC.DIADEMA, 13219365 - SIG DEL.SEC.DIADEMA, 131/20/305 - SIG DEL.SEC.DIADEMA, 2210950 - SIG DEL.SEC.DIADEMA

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

Davi Benatti Chaves

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Patrícia Helena Hehl Forjaz de Toledo

Vistos.

DAVI BENATTI CHAVES, qualificado a fls. 04, está sendo processado pela prática do crime tipificado no artigo artigo 33, “caput”, da Lei nº 11.343/06, c.c. artigo 61, inciso II, alínea, j, do Código Penal, porque no dia 26 de agosto de 2020, por volta das 15h20, na Rua Tóquio, n.º 10, Centro, nesta cidade e comarca de Diadema, vendia e trazia consigo, para fins de entrega a consumo de terceiros, 21 invólucros plásticos do tipo “Eppendorf” contendo cocaína, com peso aproximado de 15,69 gramas, 62 invólucros plásticos contendo cocaína na forma de crack, com peso aproximado de 4,84 gramas e 24 invólucros plásticos contendo Cannabis sativa L, vulgarmente conhecida como “maconha”, com peso aproximado de 27,1 gramas, substâncias entorpecentes causadoras de dependência física e psíquica, sem

autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 17/18, laudo de constatação de fls. 23/24 e laudo de exame químico toxicológico de fls. 63/65.

Concedida a liberdade provisória ao réu (fl.48/50), que foi notificado (fl. 113). Não sendo hipótese de arquivamento, a denúncia foi recebida em 20/03/2022 (fl.126) e certificada a citação positiva do Réu a fl. 148.

Em audiência de instrução, debates e julgamento foram ouvidas duas testemunhas comuns e interrogado o réu ao final. Encerrada a instrução sem requerimento de diligências, seguiu-se com os debates orais (tudo em mídia digital).

Nestes, o Órgão Ministerial requereu a procedência da ação por provadas autorias e materialidade delitivas. Pleiteou a fixação da pena base acima do mínimo diante da quantidade e nocividade da droga cocaína, com as atenuantes da confissão e da menoridade relativa, concordando com a redução da pena em percentual intermediário, mas não também por sua substituição por pena restritiva de direitos, fixando-se regime prisional semiaberto.

Já o d. Defensor Público reiterou o pedido de absolvição ante a fragilidade probatória. Subsidiariamente, requereu que a pena-base fosse fixada no mínimo legal, com as duas atenuantes (da confissão e da menoridade relativa), com o redutor da pena em seu percentual máximo, bem como sua substituição com fulcro no art. 44 do CP, fixando-se regime aberto e possibilidade de recurso em liberdade.

É o breve relatório.

Passo a fundamentar e decidir.

A ação procede em parte, por não ser hipótese de se acolher a agravante da calamidade pública, como veremos adiante.

A materialidade delitiva vem estampada no auto de exibição e apreensão de fls. 20/21, nos laudos de constatação e no definitivo (respectivamente às fls. 25/27 e 66/68), ambos positivos para as drogas maconha e cocaína.

A autoria é inconteste não só com fulcro na prova amealhada extrajudicialmente, como na colhida sob o manto do contraditório que corrobora àquela e a qual passo a expor.

Segundo narrativas administrativas dos policiais civis (fls. 05/06), estavam em patrulhando pelo local dos fatos, lugar conhecido pelo tráfico de drogas ("biqueira"), ocasião em que desembarcaram da viatura caracterizada. Carlos ente entrou por um lado da travessa e o seu parceiro pelo outro lado. Carlos visualizou um indivíduo, posteriormente identificado como sendo DAVI BENATTI CHAVES, abaixado mexendo numa sacola e com pessoas ao redor pegando alguma coisa e saindo. Aproximou-se e realizou a abordagem, momento em que as pessoas ao redor correram, sendo localizadas dentro da sacola plástica 24 unidades de substância aparentando maconha, 21 invólucros aparentando ser cocaína, e 62 unidades aparentando ser crack; localizaram também R\$ 27,00 (vinte e sete reais) que estavam dentro da sacola com as drogas. Questionado, Davi confessou estar traficando drogas no local.

Sob o crivo do contraditório o policial Carlos André Rodrigues reiterou que o local é um ponto conhecido de venda de drogas. Fizeram a incursão. Viu o réu contando as drogas numa sacola, e foi detido de pronto. No interior da sacola tinha dinheiro e os três tipos mais comuns de entorpecentes, cerca de uns cem invólucros. O réu estava parado, sozinho, na biqueira, separando os entorpecentes, e confessou que estava na mercancia das drogas ao ser detido. Acredita que a biqueira ainda esteja

em funcionamento. Reconhece a foto de fl. 11 como sendo a do réu.

Neste sentido foi o depoimento judicial do policial Daniel Bicchi quem confirmou que participava da equipe do GARRA, e em local que já é ponto de tráfico de drogas conhecido, fizeram uma incursão, e abordaram o réu. Na posse dele tinha maconha, cocaína e pedra, e também dinheiro. Ele admitiu que estava no movimento. O conduziram até o distrito policial. Foi a primeira vez que o viu naquela biqueira. Às reperguntas do MP respondeu que o réu foi surpreendido com uma sacola e com as drogas porque não deu tempo dele correr nem de dispensar a sacola. Só ele foi abordado.

O réu, em solo policial (fl.07) respondeu que estava traficando drogas no local pois está desempregado; que estava traficando há uma semana; que estava no ponto de tráfico vendendo drogas quando foi abordado por policiais civis, que localizaram maconha, crack e cocaína, juntamente com R\$ 27,00 que estavam dentro de uma sacola plástica; que a maconha custava R\$ 5,00 ou R\$ 10,00, cocaína custava R\$ 10,00 ou 20,00 e crack R\$ 5,00 ou R\$ 10,00, a depender do tamanho; que ganhava 10% a cada venda realizada, que é usuário de maconha e cocaína mas nunca se submeteu a tratamento médico.

Em juízo o acusado confessou que estava no tráfico, por ser usuário, ficou com dívida e teve que trabalhar para pagar, e tinha que ficar por perto para não fugir, e como foi preso, a dívida está paga. Não foi processado antes.

Logo, o interrogatório com a confissão do acusado, que não é prova única, pois veio corroborada pelos depoimentos dos testemunhos - que são válidos e eficazes para a convicção condenatória, até por não haver dúvidas sobre sua lisura - estão em consonância com os demais elementos probatórios contidos nos autos, sendo corroborados pelo auto de apreensão e exibição, além das provas periciais.

Não bastasse isso, é cediço que no crime de tráfico de drogas, em regra, a prova é baseada nos depoimentos dos policiais. A defesa não apresentou nenhuma prova concreta capaz de ilidir as declarações dos policiais militares, não havendo motivo plausível para seu desmerecimento, consoante Enunciado 70 da Súmula de Jurisprudência do STJ.

Ainda que não presenciado ato de comércio pelos policiais, as circunstâncias do flagrante demonstram a conduta prevista no art. 33, caput, da Lei de Drogas, que consigna como verbos nucleares trazer consigo, condutas perpetradas pelo réu, comprovada a circulabilidade. O tráfico de drogas é crime de ação múltipla e a prática de um dos verbos contidos no art. 33, caput, é suficiente para a consumação da infração, sendo prescindível a realização de atos de venda do entorpecente.

Afasto tese de se tratar o réu de mero usuário, posto que não demonstrado cabalmente como lhe competia o ônus dessa prova. Ademais, a condição de usuário de drogas não afasta a traficância, uma vez que é comumente sabido que dependentes químicos utilizam o tráfico de entorpecentes como meio de perpetuar o vício, de modo que as condutas coexistem, não se excluem, donde afastado o pedido de desclassificação. A condição de usuário não elide a responsabilização do agente pelo tráfico de drogas, pois é comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, o qual vende entorpecente para sustentar o próprio vício (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira).

Por fim, não há que se falar em situação de pobreza, estado de necessidade ou desemprego a justificar a conduta delituosa, pois além de não haver prova cabal dessa condição cujo ônus compete à Defesa, os bens jurídicos são desproporcionais, por se colocar em risco a saúde pública, de interesse da sociedade, em detrimento do interesse individual, além de se tratar de crime de perigo abstrato. Vide: 'Também não há que se falar em estado de necessidade, pois não há provas nos autos

de que o apelante passava por miserabilidade extrema a ponto de ter que violar e lei para sobreviver. A mera dificuldade financeira não autoriza ninguém a praticar delitos' (TJSP, Apelação Criminal n.º 0006727-87.2004.8.26.0081, Rel. Caio Ferraz de Camargo Lopasso, 5.ª Câmara Criminal D.J.E., j. em 29.07.2011).

À luz do art. 28, § 2º, da Lei 11.343/06, a natureza da droga (cocaina), o local da prisão (um ponto de venda de drogas conhecido), o numerário apreendido (fl.64), são fatores que, reunidos, permitem a conclusão indubitável de que o elemento subjetivo do agente dirigia-se especificamente à mercancia e não ao mero consumo pessoal, de modo que a procedência do pedido é inarredável.

Passa-se, pois, à dosimetria da pena.

Observado o art. 59 do Código Penal, os motivos, circunstâncias e consequências do delito a não demandar aumento inicial na pena, mas sim a alta quantidade de narcótico apreendido (107 invólucros no total), às vistas do disposto no art. 42 da Lei de Drogas, fixo em primeira fase, a pena base acima do mínimo: 05 anos e 06 meses de reclusão e 550 dias-multa.

Em segunda fase, não há circunstâncias agravantes. Quanto à do art. 61, II, "j", do CP, embora os fatos tenham se dado em época da pandemia pelo Covid 19, entendo não haver prova cabal de que o agente tenha se aproveitado, de modo consciente e voluntário, dessa situação especial à prática delitativa, ou que tenha se valido da facilidade que dela decorreu como: dificuldade de policiamento, menor cuidado por parte da vítima ou uma situação dramática pela qual passasse, incapacitando-a total ou parcialmente de defesa, por estar fragilizada ou adoentada, a merecer maior grau de reprovabilidade da conduta, dada a ausência de solidariedade humana e frieza moral. Ademais, não houve invasão da esfera de individualidade de terceira pessoa. Neste sentido vide: Por unanimidade, a 1ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo afastou a agravante de crime cometido em período de calamidade pública, conforme o artigo 61, inciso II, alínea j, do Código Penal, pois, segundo o relator, desembargador Andrade Sampaio, "não restou devidamente comprovado nos autos que o réu se aproveitou das circunstâncias de fragilidade, vulnerabilidade ou incapacidade geradas pelo estado de calamidade pública decretado em virtude da pandemia da Covid-19" (TJ-SP / Proc. 1512067-20.2020.8.26.0228). Ademais, a biqueira já estava e prossegue estabelecida no local, antes e a despeito da pandemia da Covid19.

Mas presente as atenuantes da menoridade relativa (fl.07) e da confissão espontânea a reduzir a pena ao mínimo legal (05 anos de reclusão e 500 dias-multa) não podendo ir aquém disso consoante Súmula 231 do STJ.

Em terceira etapa, não concorrem causas de aumento de pena. Quanto ao previsto no §4º, do art. 33, da Lei 11.343/06, sendo hipótese de "tráfico privilegiado", o Réu faz jus ao beneplácito legal, porquanto seja primário (fls.81/82), e considerando a apreensão de dinheiro, ainda que de pequena monta (R\$ 27,00 - fl.64), mas a indicar que venda de drogas a usuários foi feita, somado à natureza de maior parte das drogas, especialmente o crack de alto poder viciante e degradante da saúde humana, a demonstrar que o réu disseminou e contribuiu com o vício e teve maior envolvimento com a mercancia ilícita, entendo que o redutor de 3/5 é o razoável e proporcional, totalizando assim 02 anos de reclusão e 200 dias-multa, cada qual fixado em 1/30 do valor do salário mínimo atual tendo em conta ausência de elementos nos autos indicativos da capacidade financeira do Condenado.

O quantum da condenação, a primariedade, a análise favorável das circunstâncias judiciais permitem ao réu, primário, relativamente menor e confesso, iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade no regime aberto a teor do disposto nos artigos 33, do Código Penal, até porque o crime não foi praticado com violência nem

grave ameaça à pessoa.

Contudo, incabível a benesse do art. 44 do CP, não se mostrando suficiente nem eficaz à reprovação da conduta do agente, menos ainda socialmente recomendável sob pena de potencializar a sensação de insegurança e intranquilidade social, a merecer maior reprovabilidade a conduta, dado que viola mais intensamente o bem jurídico tutelado, somado ao elevado número de ocorrências de tal natureza conferindo constante desassossego à sociedade, a exigir firme repressão do Estado como forma de desestimular o crime, geralmente cometido graças ao nível de organização próprio daqueles que fazem do tráfico seu meio de vida. Não bastasse isso: O artigo 44, caput, da Lei de Drogas veda, expressamente, a substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de direitos para o condenado pelos crimes previstos nos artigos 33, caput e parágrafo 1º, e 34 a 37. Já o artigo 33, parágrafo 4º, da Lei de Drogas, que prevê uma causa de diminuição de pena, também estabelece, no caso de sua aplicação, que a pena privativa de liberdade não poderá ser substituída por restritiva de direitos. Ainda, a 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de não ser possível a aludida substituição para o condenado por tráfico de drogas e condutas correlatas (artigos 33, caput e parágrafo 1º, e 34 a 37), bem como quando da aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, parágrafo 4º, da Lei de Drogas (HC 144.915/MG, Rel. Laurita Vaz, v.u., j. 01.06.2010. No mesmo sentido – STJ – HC 136.618/MG, 5ª t., Rel. Min. Laurita Vaz, v.u., j. 01.06.2010). ... Ora, não nos parece razoável proceder a substituição para autor de crime de suma gravidade. A personalidade, a conduta social e culpabilidade do traficante de drogas e de quem de qualquer forma o auxilia, bem como as consequências do crime, que são nefastas para o viciado e usuário e para a sociedade, não recomendam a substituição, que pode ser indeferida nos termos do artigo 44, III, do Código Penal. Ressalte-se, por fim, que a droga é o câncer que assola a todo o mundo já que, direta ou indiretamente, é responsável por boa parte dos crimes violentos que o afligem. Por causa dela as pessoas matam ou são mortas. É muito difícil um crime violento não ter a droga como estopim. Ou o agente está sob seu efeito, ou é vítima de um traficante ou de um drogado, ou é um traficante que mata um rival etc. Enfim, a droga, de uma maneira ou de outra, está ligada aos crimes mais graves.

Permito o recurso em liberdade diante do princípio da presunção de inocência, dado já estar o réu em liberdade, tendo comparecido a esta audiência, ainda que tardiamente, e me valho do princípio da presunção de inocência.

Por fim, não há valor mínimo de reparação do dano a ser arbitrado.

Dispositivo.

Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A PRESENTE AÇÃO contra DAVI BENATTI CHAVES, qualificado a fls. 04, pela prática do crime tipificado no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, e o faço para condená-lo à pena de 02 anos de reclusão, em regime aberto, mais ao pagamento de 200 dias-multa, cada qual fixado em 1/30 do valor do salário mínimo à época dos fatos corrigido monetariamente à data do efetivo pagamento.

Absolvo o réu das penas do artigo 61, inciso II, alínea, j, do Código Penal, com fulcro no art. 386, VII do CPP.

O condenado poderá apelar em liberdade.

Sendo ele assistido pela DPE, reconheço suspensa a exigibilidade de custas e despesas processuais, por ora.

Decreto a perda de valores apreendidos nestes autos (fl. 64), com fulcro no art. 63 da Lei 11.343/06. E determino a incineração das drogas.

Com o trânsito em julgado desta sentença, certifique-se e extraia-se a guia de recolhimento definitiva em relação à pena corporal, encaminhando-se à V.E.C. Competente, certificando-se o necessário.

Oficie-se ao Senad, ao IIRGD e TRE.

Publicada em audiência, saem os presentes cientes e intimados. Cumpra-se.

Diadema, 18 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA